

재직조건부 상여금의 통상임금 인정, 그 의의와 남은 과제

○ 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 및 2023다302838
전원합의체 판결

정 현 주(법학박사, 공인노무사)

[판결요지]

사용자와 근로자는 임금 구조와 체계, 개별 임금 항목의 유형과 내용, 임금 총액 등을 자유롭게 정할 수 있고, 임금에 관한 조건도 자유롭게 부가할 수 있다. 그 조건은 강행규정에 위반되거나 탈법행위에 해당하는 등 별도의 무효 사유가 존재하지 않는 한 효력을 가진다. 그러나 조건의 효력 문제와 그 조건이 부가된 임금 항목의 통상임금성 문제는 구별하여야 한다. 전자는 ‘자율’의 영역에 속하고, 후자는 ‘후견’의 영역에 속한다. 가령 어떤 임금 항목에 재직조건이 부가되어 있어 그에 따를 때 기준 시점에 재직하지 않는 근로자에게는 해당 임금이 지급되지 않더라도, 그 임금 항목이 다른 법정수당의 산정 기초를 이루는 통상임금인지는 이와 별도로 판단할 문제이다.

1. ‘소정근로의 대가 = 통상임금’이라는 단순한 공식의 분명한 확인

대상 판결은 2013. 12. 18. 선고된 2012다89399 전원합의체 판결(이하 ‘2013년 전합 판결’)에서 제시한 통상임금 판단기준을 변경한 전원합의체 판결이다. 대상 판결은 통상임금이 가산수당 산정을 위한 기준임금으로서 본질과 기능에 충실하기 위한 속성으로 법령 부합성, 강행성, 소정근로 가치 반영성, 사전적 산정 가능성, 정책부합성을 들고 있다. 이와 같은 통상임금의 속성에 비추어 볼 때, 2013년 전합 판결에서 통상임금

판단기준으로 제시한 고정성이 통상임금의 개념적 징표가 되지 않음을 대상 판결은 상세하게 실시하고 있다. 재직조건부 상여금과 관련하여, 대상 판결은 “2013년 전원합의체 판결은 자율의 영역에 속하는 ‘조건’을 후건의 영역에 속하는 ‘통상임금’과 부당하게 결부시킨 근본적인 문제점”이라 지적하면서, 사용자가 우월적 지위에서 임금에 조건을 부과함으로써 강행적 성격을 가지는 통상임금의 범위를 부당하게 축소할 수 있다는 점을 통상임금 판단기준에서 고정성이 탈락되어야 하는 이유 중 하나로 꼽고 있다.

대상 판결은 통상임금의 개념을 재정립하면서 “소정근로시간에 제공하기로 정한 근로의 가치를 평가한 기준임금”이 통상임금의 본질이며, “근로자가 소정근로를 온전하게 제공하면 그 대가로서 정기적, 일률적으로 지급하도록 정해진 임금은 그에 부가된 조건의 존부나 성취 가능성과 관계없이 통상임금”이 된다고 실시한다. 2013년 전합 판결의 재직조건부 상여금의 통상임금성 판단기준에 대한 그간의 비판적 견해¹⁾를 적극적으로 수용하였다고 평가할 수 있다.

2013년 전합 판결의 문언에 기대어 취업규칙과 근로계약서의 임금 규정에 간단한 조건을 걸어 줌으로써 통상임금이 아닌 것이 될 수 있었던 어리석은 마술이 사라진 것이다. 어떤 임금이 통상임금인지를 확인하려면, 사용자가 임의로 설정할 수 있는 지급 조건, 지급 시기와 같은 외형이 아닌 “소정근로를 제공하기만 하면 당연히 받을 수 있는 돈인가?”라는 실제적인 질문에 곧바로 마주할 수 있게 되었다.

1) 김홍영, “통상임금에 포함시키지 않는 재직자 조건, 일정 근무일수 조건에 대한 비판적 검토”, 『노동법연구』, 서울대노동법연구회, 2014, 77쪽; 권오성, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점 -대상판결: 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결-”, 『노동법논총』, 한국비교노동법학회, 2017, 238쪽; 임상민, “재직조건부 정기상여금의 통상임금성”, 『노동법연구』, 서울대노동법연구회, 2021, 297쪽.

2. 남아 있는 문제 ①기 제공된 소정근로에 대한 대가를 지급하지 않아도 되는가?

2013년 전합 판결이 재직조건부 상여금은 고정성이 인정되지 않아 통상임금이 아니라고 판시했음에도, 전합 판결 이후에도 재직조건부 상여금의 통상임금성을 인정한 하급심 판결들이 여럿 있었다. 이 판결들이 통상임금성을 인정한 논리 전개는 두 갈래로 나뉘었다. 첫째, 재직조건부 상여금 지급 약정의 효력을 부인하고 소정근로 대가성을 인정하거나(재직조건 무효²⁾), 둘째, 재직조건 자체는 유효하지만 고정성이 인정된다고 하여 통상임금에 포함시키는(재직조건 유효³⁾) 방식이었다.

대상 판결(2020다247190)의 원심(서울고등법원 2020. 6. 19. 선고 2018나2037060 판결)은 재직조건을 무효로 보고 상여금의 통상임금성을 인정하였다. 원심이 고정 상여금을 두고 재직조건을 이유로 지급의무를 박탈할 수 없는 ‘기본급’ 또는 ‘기본급에 준하는 수당’으로서 통상임금이라고 판단한 근거는 “①사전에 확정된 금액이 계속적, 정기적으로 지급되는 임금이고, ②소정근로의 대가로 지급되는 금원일 뿐 복리후생적·실비변상적·은혜적 성격의 금원이라거나 특정 시점(상여금 지급일)의 재직에 대한 대가로 지급되는 금원이 아니며, ③총 기준급여에서 차지하는 비중, 지급 주기 등에 비추어 ‘고정급화 된 임금’으로서 그 지급 시기의 차이만 있을 뿐 통상 매월 지급되는 기준급여와 그 성격상 달리 불이유를 발견할 수 없다”는 것이다.

재직조건 자체는 유효하지만, 고정성이 인정되므로 통상임금이라고 본 서울고등법원 2016나2032917 판결⁴⁾은 고정 상여금의 소정근로 대가

2) 서울고등법원 2018. 12. 18. 선고 2017나2025282 판결; 서울고등법원 2020. 6. 19. 선고 2018나2037060 판결; 서울고등법원 2021. 1. 26. 선고 2016나2023654 판결; 서울고등법원 2021. 1. 26. 선고 2019나2017605 판결; 서울고등법원 2021. 6. 30. 선고 2020나2012736 판결 등

3) 서울고등법원 2020. 12. 2. 선고 2016나2032917 판결; 서울고등법원 2021. 7. 16. 선고 2020나2039229 판결; 서울고등법원 2021. 7. 23. 선고 2019나2017599 판결 등

4) 해당 판결에 대한 상고심(대법원 2025. 1. 9. 선고 2020다300626 판결)은 대상 판결 이후에 이루어졌는데, 대상 판결과 마찬가지로 “특정 시점에 재

성을 인정하면서 동시에 재직조건의 효력도 유효하다고 보았다. 해당 판결이 재직조건의 유효성을 인정한 근거는 ‘근로조건은 노사가 자유로이 정할 수 있으므로 사용자가 근로자에게 지급하는 각종 수당들이 반드시 근무일수에 비례하여야 한다고 할 수는 없고, 정기상여금에 붙은 재직조건은 근로자가 중도 퇴직하는 경우에 계산상의 편의를 위해 미지급 또는 초과지급 상여금을 정산하지 않기로 한 것으로서 합리적인 이유가 있고, 재직자 조건으로 인해 미지급되는 임금은 분할 지급액의 일부에 해당하는 금액으로 그 액수가 많지 않고 발생하는 상황도 예외적’이라는 것이다.

재직조건의 유효성을 판단함에 앞서, 이 조건이 근로자에게 미치는 영향을 구체적으로 살펴볼 필요가 있다. 재직조건으로 인해 고정 상여금지급이 제한되는 경우는 퇴직 외에도 육아휴직⁵⁾, 개인사정에 의한 휴직이나 정직 등이 해당할 수 있는데, 기업실무상 퇴직 외에도 재직조건을 달성하지 못하는 경우는 종종 발생한다. 재직조건이 유효함을 전제로 미지급되는 임금액을 구체적으로 계산해 본다. 월 기본급여 300만원을 전제하고 대상 판결과 유사하게 지급일 당시 재직을 조건으로 기본급여의 850%에 해당하는 고정 상여금을 매 짝수월과 두 번의 명절에 각 100%씩, 여름휴가에 50%를 지급한다는 조건으로 계산했다. 1년 동안 계속 재직한 근로자와 9개월 근무 이후 퇴직(또는 휴직)한 근로자와 임금액을 비교해 보면, 1년간 소정근로를 온전히 제공함으로써 연간 61,500,000원의 통상임금을 받을 수 있다. 그러나 9개월간 근로를 제공한 근로자는

직 중이어야 한다는 조건이 부가되어 있다는 사정만으로 그 임금의 소정근로 대가성이나 통상임금성이 부정되지 않는다”는 원칙만 확인할 뿐 재직조건의 유효성에 대한 판시를 별도로 하지 않았다.

- 5) 유정민, “통상임금 고정성 도그마의 종언”, 『연세법원논총』, 연세대학교 법학연구원, 2024, 24쪽. “육아휴직에 관하여 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률 제19조 제3항은 “사업주는 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 해서는 아니 되며”라고 규정하고 있는바, 상여금에 부가된 재직자 조건으로 인하여 육아휴직 신청 시점에 따라서는 이미 제공한 근로에 상응하는 부분을 지급받지 못할 수 있다고 한다면, 이는 위 법률에 위반되는 ‘불리한 처우’로서 재직자 조건이 무효라고 판단할 사정이 추가된다고 할 것이다.”

소정근로를 온전히 제공한 대가로 43,500,000원의 통상임금을 받게 된다. 연간 통상임금의 9/12에 해당하는 금액을 단순 계산하면 46,125,000원인데, 재직조건이 있는 바람에 2,625,000원이 적게 지급되는 셈이다. 위 예시 사례는 연간 9회 분할 지급의 경우지만, 고정 상여금의 지급 주기를 더 길게 설정한다면 그 금액의 차이는 훨씬 벌어지게 된다. 극단적으로 12월 31일 재직자에 한하여 기본급여 850%의 고정 상여금을 일시에 지급한다는 재직조건을 설정한다면, 연도 중 퇴직자나 휴직자는 상여금 전액을 지급받지 못하게 된다. 소정근로를 온전히 제공하였음에도 1년의 재직기간을 채우지 못하였다는 이유로 상당한 금액의 임금손실을 감수해야 한다. 재직조건을 둠으로써 근로자의 의사에 반한 근로를 강제할 수 있는 것이다.

대상 판결(2020다247190)은 재직조건부 상여금의 통상임금성 판단 부분에서 “원심이 고정성을 통상임금의 개념적 징표로 보아 이를 전제로 판단한 부분은 잘못이나, 이 사건 상여금을 통상임금으로 인정한 원심의 결론은 정당하다”고 설시하였을 뿐, 재직조건의 효력을 직접적으로 판단하지는 않았다. 하지만 이에 앞서 고정성을 통상임금 판단기준에서 제외하고 통상임금성 판단의 새로운 기준을 제시하면서 임금지급 조건에 관하여 “강행규정에 위반되거나 탈법행위에 해당하는 등 별도의 무효 사유가 존재하지 않은 한 효력을 가진다”고 판시하고 있어 재직조건의 유효성을 인정한 것으로 읽혀질 수 있다⁶⁾. 대상 판결은 재직조건의 유효성을 인정할 수 있는 판단기준을 제시하지 않았으며, 무효설이 재직조건부 지급은 임금의 사전포기로 근로기준법의 강행규정성에 반한다고 지적한 부분⁷⁾에 대한 반대 논거도 언급하지 않았다. 아쉽지만 대상 판결을 재직조건 미성취로 인한 상여금 미지급에 관한 다툼이 아닌 통상임금성에

6) 대상 판결의 취지에 따라 고용노동부가 개정한 「통상임금 노사지도 지침 (2025. 2. 6.)」에서는 “특정시점 재직조건 등을 부가하는 것은 해당 임금의 지급기준이나 지급대상을 정하는 것으로 그 임금을 포기하게 하거나 박탈하는 것이라 보기 어려우므로 원칙적으로 유효함”이라고 적시하고 있다. 재직조건이 유효하다는 확실한 전제에서 출발하여 사업장 지도를 하겠다는 의지로 보이는 점이 우려된다.

7) 임상민, 앞의 논문, 308쪽; 권오성, 앞의 논문, 246쪽.

관한 판결로 제한적으로 해석하고, 재직조건의 효력에 대한 판단기준은 이후 상여금 지급을 구하는 소송에서 구체적으로 다루어질 수 있기를 기대해 본다.

3. 남아있는 문제 ② 소정근로의 대가가 정기불 원칙의 예외가 될 수 있는가?

근로기준법 제43조(임금지급)⁸⁾는 임금의 직접불, 통화불, 전액불, 정기불 원칙에 대한 강행규정이다. 고정 상여금은 매월 지급되는 임금이 아니다. 그렇다면 소정근로의 대가인 고정 상여금이 동조 제2항의 정기불 원칙의 예외가 될 수 있는지가 문제된다. 예외가 아니라면 강행규정을 위반한 약정으로 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금이라는 형사처벌의 대상이 될 수 있다. 정기불 원칙의 예외가 되는 임금은 대통령령 제23조(매월 1회 이상 지급하여야 할 임금의 예외)에서 정하고 있는데, 고정 상여금이 동 시행령 제3호의 “1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금”에 해당하는지 검토되어야 한다.

대상 판결이 인정한 바와 같이 고정 상여금은 소정근로의 대가이다. “1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유”가 아닌 매일, 매월 소정근로를 제공하는 것만으로 사용자에게 지급의무가 발생하는 임금이다. 명칭을 상여금이라고 불렀더라도 통상임금에서 제외되지 않는 것처럼, 명칭을 상여금이라고 칭하더라도 정기불 원칙에서 제외된다고 보기 어렵다. 또한 소정근로의 대가를 월단위를 초과하여 지급함으로써 얻게 되는 장기 재직 유도, 이연 지급에 따른 자금유동성 확보 등의 이익은 사용자에게만 있다는 점도 간과해서는 안 될 일이다. 소정근로의 대가는 정기불 원칙

8) 제43조(임금 지급) ① 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다. ② 임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다. 다만, 임시로 지급하는 임금, 수당, 그밖에 이에 준하는 것 또는 대통령령으로 정하는 임금에 대하여는 그러하지 아니하다.

이 적용되어야 한다고 천명된다면 재직조건부 약정은 그 자체로 효력을 상실하게 될 것이다. 한편 2025. 10. 23. 시행되는 개정 근로기준법 제37조(미지급 임금에 대한 지연이자) 제2호에 따르면 제43조 제2항의 정기불 원칙을 위반한 임금지급은 연 20%의 지연이자까지 부담하게 된다. 소정근로의 대가인 고정 상여금을 월단위를 초과하여 지급하는 것이 허용되지 않는다면, 월단위를 초과한 주기로 지급된 상여금에 대한 지연이자 부과 여부와 같은 파생적인 법적 쟁점까지 야기될 수 있다.

재직조건부 고정 상여금에 대한 통상임금성 판단기준은 강제근로 금지, 임금의 전액불, 정기불 지급 원칙, 임금체불에 대한 지연이자의 부담 등 연관된 근로조건과도 호응하여 해석될 수 있어야 한다. 대상 판결이 통상임금에 대한 본질적인 개념을 명확히 제시하였다는 기쁨 뒤에 남아 있는 숙제다.